

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2121/2533

นาย ทองคำ ผาพันธ์
นาง รัตนา ตั้งมณี พิทักษ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1382, มาตรา 1387

ป.วิ.พ. มาตรา 161

โจทก์เดิน ผ่านที่ดินของจำเลยโดย ถือ วิสาสะ แม้จะใช้ มาเกินกว่า10 ปี ก็หา
ก่อให้เกิดการจำยอมเหนือที่ดินจำเลยไม่ คดีมีการนัดชี้สองสถานและได้ นัดสืบพยาน
โจทก์จำเลยรวม ทั้งสิ้น15 นัด เป็นเวลา 1 ปีเศษ ทนายความจึงต้อง ว่าความนานพอ
สมควร และเป็นคดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ฎีกาใน ปัญหาข้อเท็จ
จริงถือ เป็นคดีสำคัญ ศาลชั้นต้นกำหนดค่าทนายความ 3,000 บาท จึงเหมาะสมกับ
รูปคดี.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โฉนดเลขที่ 5602, 226และ 240
และปลูกบ้านอยู่ในที่ดินโฉนดเลขที่ 226 ส่วนที่ดินโฉนดเลขที่ 240 อยู่ห่างไปทาง
ทิศเหนือประมาณ 300 เมตร โจทก์ได้เข้าออกที่ดินโฉนดเลขที่ 240 โดยใช้ทางเดิน
ผ่านที่ดินโฉนดเลขที่9780 และ 42334 ของจำเลย มีความกว้างประมาณ 1.25
เมตร มาเป็นเวลาประมาณ 30 ปี ไม่มีผู้ใดโต้แย้งขัดขวางแต่อย่างใด ต่อมาเมื่อวันที่
18 มกราคม 2528 จำเลยได้นำสั้งกะสีมาตีปิดกั้นทางเดินดังกล่าวที่จะออกสู่ซอยปริ

ยานนท์ทำให้โจทก์ได้รับความเดือดร้อนเสียหายไม่อาจใช้ทางภาระจำยอมนี้ได้ขอให้
บังคับให้จำเลยเปิดสัγκะสีที่ตีปิดเส้นทางออกมีความกว้าง 1.25 เมตร ถ้าไม่ยอมให้
โจทก์ทำการเปิดสัγκะสีได้เอง โดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ให้จำเลยไปจดทะเบียน
ทางภาระจำยอม หากไม่ยอมให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของ
จำเลย

จำเลยให้การว่า จำเลยซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 9780 และ 42334มาจากนายเอม
สุขเสมอ และนายเชิด ณ ป้อมเพชร จำเลยยอมรับว่าที่ดินของจำเลยทั้งสองแปลง
เคยมีทางเดินอยู่ในที่ดิน แต่เป็นทางที่เจ้าของที่ดินต่างใช้ทางเดินในที่ดินของอีกคน
หนึ่งโดยถือวิสาสะ เพราะที่ดินในบริเวณดังกล่าวเดิมมีสภาพเป็นสวน เจ้าของที่ดิน
ต่างปลูกบ้านอาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อผู้เป็นเจ้าของที่ดินจะเข้าสู่ที่ดินของตน
จะต้องเดินผ่านสวนคนอื่น เจ้าของที่ดินจึงปฏิบัติต่อกันโดยถ้อยที่ถ้อยอาศัยกัน มิได้
ใช้ทางผ่านโดยมีเจตนาจะยึดถือเอาเป็นทางภาระจำยอม แม้ทางที่อาศัยเดินผ่านที่ดิน
จำเลยทั้งสองแปลงมีมานานประมาณ 30 ปี โจทก์ก็ไม่ได้ภาระจำยอม ต่อมาทาง
ราชการตัดซอยปรียานนท์ โจทก์จึงเลิกใช้เส้นทางเดินผ่านที่ดินจำเลยมาใช้ซอยดัง
กล่าวเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปี จึงไม่มีทางภาระจำยอมของที่ดินโจทก์ในที่ดินของ
จำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ตามคำฟ้องของโจทก์และคำให้การของจำเลยว่า ทางพิพาทเคยเป็นทางเดินในที่ดินของจำเลยมาก่อน มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าทางพิพาทตกเป็นภาระจำยอมโดยอายุความเพราะโจทก์ได้ใช้ทางพิพาทมากกว่า 10 ปีแล้วหรือไม่ ซึ่งศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่าการที่โจทก์ใช้ทางพิพาทเป็นทางเดินมาตามที่ฟ้องนั้น โจทก์ใช้ทางพิพาทเป็นทางเดินมาด้วยหลักถ้อยที่ถ้อยอาศัยกัน โดยวิสาสะหาก่อให้เกิดภาระจำยอมขึ้นไม่ และโจทก์ฎีกาในปัญหาข้อนี้ว่า โจทก์จำเลยมิได้เป็นคนรู้จักคุ้นเคยกัน โจทก์จึงใช้ทางพิพาทโดยเจตนาให้เกิดภาระจำยอม มิใช่ออย่างถ้อยที่ถ้อยอาศัยกันโดยวิสาสะ คดีนี้โจทก์นำพยานเข้าสืบรวม 3 ปาก ทั้งตัวโจทก์ คงมีเฉพาะตัวโจทก์เท่านั้นที่ยืนยันว่าโจทก์มิได้ใช้ทางพิพาทอย่างวิสาสะ แต่นายตุ้ มีเดชพยานโจทก์คนหนึ่งกลับเบิกความว่า ที่มีการเดินผ่านร่องสวนของกันและกัน แต่ไม่มีการโต้แย้งคัดค้านกันนั้น เพราะต่างก็ถ้อยที่ถ้อยอาศัยกันจึงเชื่อมกับที่จำเลยนำสืบ ข้อเท็จจริงจึงเชื่อได้ตามข้อต่อสู้ของจำเลยว่า ทางเดินในที่ดินของจำเลยนั้นเป็นทางเดินที่เจ้าของที่ดินข้างเคียงต่างใช้เดินผ่านโดยหลักถ้อยที่ถ้อยอาศัยกันโดยวิสาสะจึงหาก่อให้เกิดภาระจำยอมไม่ การที่โจทก์อ้างว่าโจทก์ไม่ได้เดินอย่างถ้อยที่ถ้อยอาศัยกันโดยวิสาสะก็เป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ โจทก์มิได้นำสืบแสดงให้เห็นข้อแตกต่างกว่าผู้อื่นแต่อย่างใด นอกจากอ้างว่ามิได้รู้จักคุ้นเคยกับจำเลยจึงไม่เป็นการวิสาสะเท่านั้น ศาลฎีกาเห็นว่า ข้ออ้างดังกล่าวยังรับฟังไม่ได้ว่าโจทก์มิได้ใช้ทางพิพาทอย่างวิสาสะ ศาลล่างทั้งสองพิพากษาว่าทางพิพาทมิได้ตกอยู่ในภาระจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์ชอบแล้วโจทก์ฎีกาเป็นข้อสุดท้ายในปัญหาค่าฤชาธรรมเนียมว่าศาลชั้นต้นกำหนดค่าฤชาธรรมเนียมสูงเกินสมควรนั้น ศาลฎีกาตรวจสำนวนแล้วปรากฏว่าคดีนี้มีการนัดชี้สองสถานและนำสืบพยานโจทก์จำเลยรวมทั้งสิ้น 15 นัด เป็นเวลานาน 1 ปีเศษ นับเป็นเวลาที่ทนายความต้องมาว่าความนานพอสมควร ประกอบกับคดีนี้เป็นคดีเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นคดีสำคัญ ดังเห็นได้จากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งไม่ห้ามอุทธรณ์ฎีกาใน

ปัญหาข้อเท็จจริง ดังนั้น ที่ศาลชั้นต้นกำหนดค่าเสียหายความให้ 3,000 บาท จึงเหมาะสมกับรูปคดีแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พืพำกษำยืน.

(วิทวัส อยู่วัฒนา-บุญส่ง วรรณกลาง-ตัน เวทไวย)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ

การจำยอม Servitude เป็นทรัพย์สินสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีผลเป็นการรื้อถอนหรือจำกัดสิทธิของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1387 บัญญัติว่า"อสังหาริมทรัพย์อาจต้องตกอยู่ในการจำยอมอันเป็นเหตุให้เจ้าของต้องยอมรับกรรมบางอย่างซึ่งกระทบถึงทรัพย์สินของตน หรือต้องงดเว้นการใช้สิทธิบางอย่างอันมีอยู่ในกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินนั้น..."บันทึกนี้จะพิจารณาเฉพาะทาง การจำยอมซึ่งมักเกิดเป็นกรณีพิพาททาง การจำยอมเป็นสิทธิที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้ ส่วนทางจำเป็นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1349 เป็นข้อจำกัดกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินที่จำต้องยอมให้เขาเดินผ่านที่ดินของตน ด้วยเหตุจำเป็นที่เขาถูกปิดล้อมไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะได้เป็นคนละเรื่องกับทาง การจำยอม ทางการจำยอมอาจได้มา 2 กรณี คือ 1. โดยนิติกรรม byJuristicacts และต้องอยู่ภายใต้บังคับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299 วรรคหนึ่ง

กล่าวคือต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ มิฉะนั้นนิติกรรม
ไม่บริบูรณ์ 2. โดยอายุความ byprescription ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1401 บัญญัติว่า "การจำยอมอาจได้มาโดยอายุความ ท่านให้นำบทบัญญัติว่า
ด้วยอายุความได้สิทธิอันกล่าวไว้ในลักษณะ 3 แห่งบรรพนี้มาใช้บังคับโดย
อนุโลม" อายุความได้สิทธิที่นำมาใช้ คือ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1382 เป็นกรณีเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ใกล้เคียงใช้สอยอสังหาริมทรัพย์ของผู้
อื่น ด้วยความสงบเปิดเผยและด้วยเจตนาจะให้ได้สิทธิการจำยอมใน
อสังหาริมทรัพย์นั้นติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งเป็นการใช้สิทธิโดย
ปรักษ์ต่อเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ อันมีลักษณะเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตหรือ
กระทำที่มีชอบด้วยกฎหมาย unlawful acts ซึ่งมีความหมายกว้างกว่าการกระทำผิด
กฎหมาย illegal acts หากเป็นการเข้าใช้สิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่นเจ้าของ
อนุญาตให้ใช้ก็ไม่ใช่เป็นการใช้สิทธิโดยปรักษ์ การพิสูจน์ว่าอย่างไรเป็นการใช้สิทธิโดย
ปรักษ์ต้องอาศัยข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่แสดงออกแต่ละเรื่องแต่ละรายไปเป็น
ข้อวินิจฉัย ปัญหาการใช้ทางเดินในที่ดินของคนอื่นโดยปรักษ์เพื่อให้ได้ทางภาร
จำยอมจะเริ่มนับตั้งแต่เวลาใดเป็นข้อพิสูจน์ยาก หากมีการใช้ทางเดินโดยเจ้าของไม่
ยินยอมอนุญาต หรือการขออาศัย กฎหมายจึงสันนิษฐานว่าเป็นการใช้สิทธิเพื่อ
ตนเอง ตั้งแต่เริ่มแรกที่มีการใช้สิทธิโดยปรักษ์อาจจะเกิดขึ้นในภายหลังที่มีการ
ใช้สอยอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นแล้วก็ได้ กล่าวคือ ในตอนแรกเจ้าของที่อนุญาตให้
เดินผ่านได้ ต่อมาจะเปลี่ยนการใช้ทางเดินโดยปรักษ์ก็ได้ แต่ต้องแจ้งเจตนา
เปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้สิทธิอาศัยเป็นใช้สิทธิโดยปรักษ์ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1381 และตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1072/2529
วินิจฉัยว่า "...ได้ความจากคำเบิกความของโจทก์เองว่าโจทก์ใช้ทางพิพาทด้วยถือ
วิสาสะจึงฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์ยังใช้ทางพิพาทโดยถือวิสาสะเช่นเดิมอีกดังนี้ จะ
ถือว่าทางพิพาทเป็นการจำยอมแก่โจทก์หาได้ไม่ เพราะโจทก์ได้ใช้ทางพิพาทตลอด

มาโดยถือวิสาสะต่อมานายสนอง โอนขายที่ดินโฉนดเลขที่ 356 ให้จำเลยเมื่อ พ.ศ. 2521 และโจทก์ใช้ทางพิพาทต่อมาจนกระทั่งจำเลยปิดล้อม แม้โจทก์จะถือว่าโจทก์ใช้ทางพิพาทในช่วงนี้โดยไม่ใช้การถือวิสาสะแต่ก็ยังไม่ถึงเวลา 10 ปีทางพิพาทจึงยังไม่เป็นการจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์..." ตามคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวเป็นกรณีโจทก์เปลี่ยนการใช้ทางพิพาทจากโดยถือวิสาสะมาเป็นการใช้สิทธิอย่างปรบักษ์ ปัญหาว่าการใช้สิทธิโดยปรบักษ์จะต้องใช้ตลอดเวลาหรือไม่เพราะมาตรา 1382 ใช้ถ้อยคำว่า "ติดต่อกัน" ตรงกับภาษาอังกฤษว่า "uninterrupte" กรณีนี้ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยวางบรรทัดฐานไว้ว่าการใช้สิทธิโดยปรบักษ์ไม่จำเป็นต้องใช้ตลอดเวลาเพียงแต่มีการใช้ตามโอกาสที่พึงใช้ได้ตามฤดูกาล หรือประเพณีแห่งท้องถิ่นก็ถือว่าใช้ติดต่อกันแล้ว ดังนั้นคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 473/2481 วินิจฉัยว่า "เมื่อผู้ใดได้ใช้ที่ดินของผู้อื่นพากระบือผ่านไปทำนา ในที่ของตนเป็นเวลา 10 ปีเศษ แม้ในปีหนึ่งจะใช้เพียงฤดูทำนา ก็ได้สิทธิการจำยอม และดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 919/2473 และ 961/2480 ประกอบ ในกรณีเจ้าของที่ดิน "ยินยอม consent" ให้เดินผ่านจะถือว่าเป็นการใช้สิทธิโดยปรบักษ์หาได้ไม่ เพราะเป็นการเข้าใช้โดยอาศัยอำนาจของเจ้าของที่ดิน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน วิเคราะห์ศัพท์คำว่า "ยินยอม" หมายถึง ยอม, ไม่ขัด, ชอบใจ การยินยอมมีความหมายทำนองเดียวกับการอนุญาตให้เขาเดินผ่านที่ดินของตนโดยไม่ขัดขวาง เท่ากับใช้โดยอาศัยอำนาจของเจ้าของที่ดินเช่นกัน ตามพจนานุกรมฯ วิเคราะห์ศัพท์ คำว่า "อนุญาต" หมายถึง ยินยอม, ยอมให้, ตกลงผู้บันทึกเห็นว่าการยินยอมหรืออนุญาตไม่ใช่สิทธิตามกฎหมายที่จะได้รับการรับรองและคุ้มครองให้ ดังนั้น ผู้ที่ได้รับการยินยอมหรืออนุญาตให้เดินผ่านที่ดินของคนอื่นจึงไม่ได้รับการรับรองและคุ้มครองตามกฎหมายหากเจ้าของที่ดินจะหวงห้าม ไม่ยินยอมหรือปิดกั้นทางเสียเมื่อไหร่ก็ได้ เพราะเป็นการใช้สิทธิเหนือทรัพย์สินของตนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1336 หาเป็นการละเมิดไม่ การยินยอมอาจจะเกิดขึ้นก่อนหรือภายหลังที่มีการเดินผ่านแล้วก็ได้ เช่น เจ้าของที่ดินยินยอมให้

เจ้าของที่ดินข้างเคียงเดินผ่านหรืออาจจะเป็นการใช้สิทธิเดินผ่านโดยปรักกษ์ในตอนแรกเจ้าของที่ดินทุกท่งแต่ในที่สุดยินยอมให้เดินผ่านโดยดี เมื่อเจ้าของที่ดินยินยอมก็หาก่อให้เกิดการจำยอมไม่ แม้จะใช้สิทธิเดินผ่านที่ดินมาเป็นเวลากว่า 10 ปี ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1095/2473วินิจฉัยว่า "การที่เจ้าของที่ดินยินยอมให้ชาวบ้านใช้เกวียนและสัตว์พาหนะเดินผ่านที่ดินของตนเฉพาะฤดูกาลนั้น แม้จะเป็นมาช้านานกว่า 10 ปี ก็ดี ท่านว่าหากทำให้เกิดการจำยอมที่เจ้าของจะต้องให้ทางนั้นเป็นสาธารณะไม่" ต่อมาคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 958/2474 วินิจฉัยว่า "...การที่โจทก์เดินลัดในทางพิพาทก็โดยอาศัยพิน้องของโจทก์ได้ยินยอมให้เดินเพราะขณะนั้นที่ยังรกร้างอยู่ และนอกจากนั้นยังปรากฏว่ามีทางหลวงอีกทางหนึ่งซึ่งสาธารณชนใช้กระบือลากเลื่อนไปมาได้ โจทก์ใช้เดินไปนาโจทก์ได้เช่นเดียวกันแต่หากเดินกันจนเป็นหล่มเป็นคุ่มไม่มีใครซ่อมแซม และเป็นทางอ้อมกว่าทางรายพิพาทเพียงเล็กน้อย เป็นการสะดวกที่โจทก์จะใช้ทางนี้อยู่แล้ว ไม่มีเหตุที่จะยอมให้โจทก์ถือประโยชน์ส่วนตัวมาตัดสิทธิของจำเลย ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์..." เป็นที่น่าสังเกตว่าคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 958/2474 คล้ายกับยอมรับว่าหากโจทก์มีเหตุจำเป็นอื่น ๆ เช่น ทางเดินอื่นไม่มีเลย แม้เจ้าของที่ดินจะยินยอมก็อาจก่อให้เกิดการจำยอมได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 473/2481วินิจฉัยว่า "...คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาได้ตรวจสำนวนเรื่องนี้ตลอดและประชุมปรึกษาชี้ขาดคดีนี้แล้วเห็นว่า ในคดีเรื่องการจำยอมเช่น ทางเดินของกระบือในคดีนี้ อาจเกิดจากการยินยอมให้เดินเบื่องตันก็ได้ ปัญหาจึงมีต่อไปว่า ในนาของจำเลยนั้น มีทางเดินดังแผนที่ที่โจทก์ชี้หรือไม่...ทางพิพาทมีอยู่จริง และตามบันทึกของอำเภอกที่ 21/5/2480 จำเลยก็แจ้งต่ออำเภอกว่ามีทางในนาจำเลยจริง...โจทก์ใช้ทางนี้เพียงเดือน 7 ถึงเดือน 12 ศาลฎีกาเห็นว่าฐานะของโจทก์ก็คือเอากะบือไปนา เดือน 7 ถึงเดือน 12 เป็นฤดูทำนาโจทก์จึงต้องใช้ทางนี้ จะเรียกว่าโจทก์ใช้ชั่วคราวไม่ได้ ส่วนทางอื่นก็ไม่สะดวกเหมือนทางวิวาทนี้ เมื่อโจทก์ได้ใช้ทางเดินประจำสายนี้มาเกิน 10 ปี แล้ว โจทก์ยอมได้สิทธิการจำยอม..."คำพิพากษาศาล

ฎีกาดังกล่าวคล้ายกับศาลฎีกาย่อมรับว่า แม้เจ้าของที่ดินจะยินยอมให้เดินผ่านก็เป็น
ทางภาระจำยอมได้ จะว่าเป็นกรณีผู้เดินได้เปลี่ยนแปลงการใช้ทางอย่างปรักภักซ์เพื่อให้
ได้สิทธิภาระจำยอมข้อเท็จจริงก็ไม่ค่อยชัดเจนนัก และคำพิพากษาศาลฎีกาที่1370/2500
วินิจฉัยว่า "...ตามพฤติการณ์ดังที่เป็นมา โจทก์ได้ใช้ทางโฉนด 2787 เข้าออกทาง
ประตู หมายเลข 4 ตลอดมาช้านานเกินกว่า10 ปี แล้ว แม้ว่าจะโดยถือวิสาสะหรือ
เจ้าของที่ดินยินยอมไม่ได้แต่ยังปล่อยให้ใช้เรื่อยมาเช่นนี้ โจทก์ย่อมได้มาซึ่งสิทธิภาระ
จำยอมโดยทางขาดอายุความแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
1387 และ1401" คำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าว ศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ชัดว่ากรณีเจ้าของ
ที่ดินยินยอมไม่ได้แต่ยังยอมได้ภาระจำยอม ผู้บันทึกเห็นว่าคำว่ายินยอมคงมิใช่ยินยอม
หรืออนุญาตให้ใช้ หากแต่เป็นการยอมตามหรือผ่อนปรนไม่ได้แย้ง ในกรณีที่เขาถือ
วิสาสะเข้ามาใช้ทางเดินในลักษณะเป็นปรักภักซ์ ทำให้เกิดความเข้าใจสับสนได้ แต่ใน
ระยะหลังศาลฎีกาจะใช้คำว่าอนุญาตแทนคำว่ายินยอม ปัญหาว่าการยินยอมหรือ
อนุญาตจะต้องมีทุกครั้งที่มีการใช้ทางเดินหรือไม่ เพราะการใช้ทางโดยปรักภักซ์ไม่จำ
ต้องใช้ตลอดเวลาอาจจะใช้ตามฤดูกาล หรือชั่วคราวคราวในแต่ละปีศาลฎีกาเคย
วินิจฉัยไว้ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 533/2500 มีถ้อยคำตอนหนึ่งว่า"...ส่วนข้อที่ว่า
ต้องขออนุญาตหรือไม่และต้องพินคันท้าที่เก่าหรือเปลี่ยนที่พินคันท้าใหม่นั้น เห็น
ว่าเมื่อนับย้อนหลังไปประมาณ 30-40 ปี ผู้คนยังน้อย และโจทก์จำเลยรวมทั้งพยาน
ก็เกี่ยวเป็นญาติกัน อาจผ่อนผันเพราะเห็นแก่ความจำเป็นในการใช้เกี่ยวขนข้าว
และใช้กระบือผ่านนาเมื่อสิ้นฤดูทำนาแล้วได้ ส่วนจะผ่านทางไหนน่าจะถือเอาความ
สะดวกของพื้นที่และของผู้ใช้เกี่ยวและกระบือผ่านเป็นประมาณ เช่น พยายามใช้
ทางให้สั้นและสะดวกที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากจะต้องขออนุญาตกันบ้างก็คงขอเฉพาะ
ครั้งแรกที่จะใช้ครั้งต่อ ๆ มาและปีต่อ ๆ มาไม่ได้ขอกันดังคำนายจรรยา กำนันพยาน
ศาล ไม่ใช่ต้องขอกันทุกปี และทุกครั้งที่ใช้เกี่ยวและกระบือผ่าน..." จากแนวคำ
พิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าการที่เจ้าของที่ดินยินยอมหรืออนุญาตให้คนอื่น

เดินผ่านที่ดิน คงถือเฉพาะการยินยอมหรือการอนุญาตครั้งแรกที่มีการเดินผ่าน หากจำเป็นต้องขออนุญาตทุกครั้งที่มีการเดินผ่านไม่ หากเจ้าของที่ดินยินยอมหรืออนุญาตตั้งแต่แรก การใช้สิทธิเดินผ่านจึงเป็นการใช้โดยอาศัยอำนาจของเจ้าของที่ดิน หากเป็นการใช้สิทธิโดยปรักษ์ต่อเจ้าของที่ดินอันจะก่อให้เกิดสิทธิได้การจำยอมไม่ เว้นแต่จะเปลี่ยนเจตนาและลักษณะการใช้สิทธิอย่างปรักษ์เพื่อตนเอง และต้องมีการแสดงเจตนาไปยังเจ้าของที่ดินให้ทราบด้วยว่าต่อไปจะเป็นการใช้สิทธิอย่างปรักษ์ ในกรณีเช่นนี้หากใช้ทางเดินครบ 10 ปี ย่อมได้ทางภารจำยอม หรือในกรณีเจ้าของยินยอมอนุญาตให้ใช้ทางผ่านมาแต่ตอนแรกและเดินมาเรื่อย ๆ ต่อมาเจ้าของไม่ยินยอมอนุญาตให้เดินผ่านแต่ผู้ใช้ทางยังขึ้นเดินผ่านเท่ากับเป็นการใช้อย่างปรักษ์เมื่อครบ 10 ปี ย่อมได้เป็นทางภารจำยอมเช่นกัน ปัญหาที่น่าพิจารณาต่อไปคือการใช้ทางเดินโดยวิสาสะ จะก่อให้เกิดการจำยอมหรือไม่ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1370/2500 วินิจฉัยว่า การใช้ทางเดินในที่ดินของผู้อื่นโดยถือวิสาสะย่อมได้สิทธิการจำยอม ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 วิเคราะห์ศัพท์คำว่า "วิสาสะ" หมายความว่า ความคุ้นเคย ความสนิทสนมการถือว่าเป็นกันเอง ลักษณะการใช้ทางเดินโดยวิสาสะ จึงมีลักษณะเป็นการอาศัยความคุ้นเคย ความสนิทสนมกันมากกว่าที่จะมีลักษณะเป็นการโต้แย้งหรือมีลักษณะการใช้สิทธิโดยมิชอบแต่อย่างใด ไม่น่าจะเข้าลักษณะของการใช้สิทธิโดยปรักษ์อันจะก่อให้เกิดการจำยอมได้ต่อมาศาลฎีกาได้วินิจฉัยกลับแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1370/2500 และได้วางหลักไว้ว่า การใช้ทางเดินโดยถือวิสาสะไม่ก่อให้เกิดการจำยอม ปรากฏในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 217/2501 วินิจฉัยว่า "...ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าโจทก์ได้ถือวิสาสะใช้ทางพิพาทเดินผ่านที่ดินของจำเลยมากกว่า 10 ปี ไม่ใช่การขออาศัยจากจำเลยศาลฎีกาเห็นว่าคำว่า วิสาสะนั้น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2493 วิเคราะห์ศัพท์ว่า ความคุ้นเคย สนิทสนม การถือว่าเป็นกันเอง และการใช้สิทธิในทางเดิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1401 นั้น ต้องเป็นการใช้สิทธินำเอากรรมมาสู่การ

ยทรัพย์โดยได้นำมาโดยปรักษ์ ครบกำหนดอายุความได้สิทธิตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 แต่คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า โจทก์ได้ถือวิสาสะใช้
ทางพิพาทเดินผ่านที่ดินของจำเลยเป็นการแสดงว่า กระทำโดยฉันทมิตรหาเข้า
ลักษณะเป็นการใช้สิทธิโดยปรักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
1382 ไม่ ฉะนั้นแม้โจทก์จะได้ใช้ทางพิพาทเดินผ่านที่ดินของจำเลยมากกว่า 10 ปีแล้ว
ทางพิพาทก็ไม่ตกเป็นภาระจำยอมตามกฎหมาย ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังขึ้น..." คำ
พิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวจึงเป็นบรรทัดฐานว่าการใช้ทางเดินโดยถือวิสาสะหาก่อให้
เกิดการจำยอมไม่ ต่อมาคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1073/2529, 2121/2530 และคำ
พิพากษาศาลฎีกาที่บันทึกหมายเหตุนี้ได้วินิจฉัยทำนองเดียวกัน. วัชรินทร์ปัจเจก
วิญญูสกุล.